

1501424-54.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa arguiu ilicitude da busca sem mandado judicial. No mérito, pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a tese ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501424-54.2020.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501424-54.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2274557/2020 - 02º D.P. PIRACICABA, 2274557 - 02º D.P. PIRACICABA, 3116/20/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE BERTOLINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

GUILHERME HENRIQUE BERTOLINO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei

11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 5 de novembro de 2020, por volta das 15 horas e 15 minutos, na rua Giocondo Marino nº 251, bairro São Jorge, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 14 porções de maconha (vegetal contendo Tetrahydrocannabinol), com massa bruta de 17,2g; e 4 “pinos” amarelos (eppendorfs) contendo cocaína, com massa bruta de 4,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, fotografia de fls. 19/26 e laudo de constatação de fls. 44/47).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 6 porções de maconha (vegetal contendo Tetrahydrocannabinol), com massa bruta de 139,1g; 139 “pinos” (eppendorfs), nas cores amarela e verde, contendo cocaína, com massa bruta de 151,6g; e um “tijolo” de maconha (vegetal contendo Tetrahydrocannabinol), com massa bruta de 774,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, fotografia de fls. 19/26 e laudo de constatação de fls. 44/47).

Narra a denúncia que o acusado se postou no local dos fatos para traficar drogas. Entretanto, Policiais Militares que passavam pelo lugar, sabedores de que ali se cometia o tráfico de drogas, suspeitaram da atitude de Guilherme. Decidiram, então, abordá-lo e submetê-lo à busca pessoal. Tal providência resultou no encontro pelos servidores públicos, em poder do acusado, de 14 porções de maconha e 4 pinos amarelos de cocaína, além de R\$ 48,00 em dinheiro trocado.

Narra, ademais, que realizada varredura nas cercanias com o auxílio de cão adestrado, localizaram uma sacola plástica contendo mais 6 porções de maconha, 45 pinos amarelos de cocaína (idênticos àqueles encontrados em poder do réu), 94 pinos verdes de cocaína, um tijolo de maconha e duas balanças de precisão.

Afirma a denúncia que as circunstâncias do achado e a semelhança entre tais porções e aquelas encontradas em poder do acusado evidenciaram que toda a droga lhe pertencia.

Em prosseguimento, os policiais ingressaram na casa do réu, no regular desdobramento da prisão em flagrante – e encontraram, no quarto dele, outras duas balanças, uma das quais com características semelhantes aos equipamentos já recolhidos – e R\$ 1.660,00 em espécie.

Conclui a denúncia que a quantidade de droga relacionada ao acusado indica sua destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 207). Defesa preliminar apresentada às fls. 211/219. Após, a denúncia foi recebida (fls. 227/230) e o réu foi citado (fls. 253).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e quatro arroladas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa arguiu ilicitude da busca sem mandado judicial. No mérito, pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a tese defensiva de nulidade da prova em decorrência da realização das diligências policiais sem mandado judicial.

A Constituição Federal expressamente autoriza a abordagem e revista pessoal, bem assim a busca domiciliar sem prévia autorização judicial em casos excepcionais, como aqueles em que há flagrante delito.

Neste sentido dispõe o artigo 5º, inciso XI:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” - gn.

O crime de tráfico, na modalidade "ter em depósito" substância entorpecente, é permanente.

E, no caso concreto dos autos havia fundadas suspeitas da prática do crime pelo réu a autorizar a ação da polícia.

De fato, revelou a prova oral que adiante será analisada, que policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual era conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu parado na rua e que, este, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, fatos que claramente indicavam que poderia estar na prática do comércio ilícito de drogas. Isso motivou a lícita abordagem, que resultou no encontro, em seu poder, de 14 porções de maconha e 4 pinos de cor amarela contendo cocaína. Na sequência, diligenciando nas proximidades, com a ajuda de um cão farejador, em um matagal existente defronte ao local da abordagem, os policiais localizaram mais 7 porções de maconha, 94 pinos de cor verde e 45 pinos de cor amarela contendo cocaína, idênticos ao apreendido com o acusado.

Evidenciada, assim, a situação de flagrante de tráfico de drogas, o que permitiu aos policiais, em desdobramento aos seus trabalhos, a realização de busca no imóvel de propriedade do réu, onde havia suspeita da ocorrência do crime permanente.

Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio réu, quando formalmente ouvido pela Autoridade Policial, na presença de seu advogado constituído e após ser cientificado de todos os seus direitos (fls. 05), declarou que autorizou os policiais a realizarem busca em sua casa, até porque sabia que não iriam encontrar substâncias ilícitas ali.

É certo que, na presença do mesmo advogado, retratou-se em juízo, afirmando que os policiais perguntaram o que tinha em sua casa e foram entrando.

A retratação, entretanto, não convence, porque não é crível que o combativo Advogado do réu, atuante em um dos escritórios de advocacia mais renomados de Piracicaba e região, não tivesse verificado, na delegacia de polícia, que a Autoridade Policial teria constado equivocadamente uma fala do réu que derrubaria uma das mais importantes teses defensivas.

Neste contexto, não há dúvidas de que o réu autorizou o ingresso dos policiais na sua casa, até para provar que não guardava nada de ilícito ali, como ele afirmou perante a Autoridade Policial.

Fica, portanto, afastada a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial, questão, entretanto, que, ainda que não fosse superada, não iria alterar o julgamento, porque, conforme se verá a seguir, a apreensão do dinheiro e objetos encontrados dentro da casa do réu não foram consideradas como elementos de

convicção do tráfico.

No sentido de que, em casos como esse, não há como se cogitar nulidade, é farta a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns recentes julgados:

“Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo que busca, preliminarmente, a nulidade decorrente de suposta invasão domiciliar. No mérito, busca a absolvição, por fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, ou a fixação de regime mais brando. Preliminar rejeitada – Nulidade por violação de domicílio – inocorrência – Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto, sendo que, a própria Constituição Federal autoriza o ingresso, dentre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito ou mediante consentimento do morador – crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, permitindo o estado de fragrância a qualquer momento – Fundadas razões que justificaram a atuação policial. Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – prisão em flagrante – apreensão de crack (171 pedras), cocaína (15 porções) e maconha (05 porções), além de quantia em dinheiro. Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Relatos seguros dos Policiais Militares narrando que o réu foi abordado em via pública na posse de drogas, assim como indicou a residência e terreno que foram localizados e apreendidos os demais entorpecentes. Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório – Condenação que se impõe. Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal, sem recurso Ministerial. Na segunda fase, circunstância agravante da reincidência (específica). Na derradeira etapa, causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 que foi bem afastada, por falta de amparo legal. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido”. (TJSP - Apelação Criminal 1501346-96.2020.8.26.0587. 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Ely Amioka – j. 10/11/2021) – g.n.

“Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. 1. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e a autorização para ingresso domiciliar dada pela sua esposa. Apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel após consentimento da moradora. Permissivo constitucional. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 2. Materialidade demonstrada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas desacompanhadas de outros elementos indicativos da destinação comercial. Negativas do réu. Diante das dúvidas quanto à destinação comercial, há de prevalecer a situação mais favorável à defesa diante da supremacia do princípio da presunção da inocência. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 3. Dosimetria. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 4. Recurso parcialmente provido.”

(TJSP - Apelação Criminal 1500145-58.2020.8.26.0623. 16ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli – j. 11/02/2021) – g.n.

Afastada a tese de nulidade arguida pela defesa, passo à análise do mérito.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

1) boletim de ocorrência de fls. 10/14;

- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e fotografias de fls. 19/26;
- 3) laudo de constatação de fls. 44/47 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 187/190, com resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) em relação às substâncias apreendidas; e
- 4) BO/PM de fls. 197/203.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05), o réu negou o crime. Disse que, na data dos fatos, estava defronte sua residência preparando um cigarro de maconha para consumo próprio, quando a viatura policial se aproximou e os PM o abordaram, perguntando por uma pessoa de nome Álvaro, que seria responsável pelo tráfico na região. Respondeu-lhes que não conhecia tal pessoa. Um deles, então, com auxílio de um cão farejador adentrou o matagal que existia ali na frente e de lá saiu com uma sacola, dizendo que estava cheia de drogas. Alegou ter dito a eles que desconhecia a origem das drogas, mas acabou admitindo conhecer a pessoa de "Álvaro", o qual residia nas proximidades. Na sequência, eles perguntaram se tinha algo ilícito em sua residência, respondeu-lhes negativamente e os autorizou que ali entrassem para realizarem a busca. Esclareceu que encontraram duas balanças de propriedade de seu genitor, o qual havia trabalhado como padeiro e as utilizava em seu ofício, além de R\$400,00, referentes a seu auxílio desemprego, e outra importância que pertencia a seu pai, o qual deixa o dinheiro guardado em casa. Eles lhe disseram que o levariam como testemunha do encontro das drogas até a Delegacia, mas em nenhum momento afirmaram que estaria preso ou sendo acusado de tráfico. Negou a propriedade das drogas encontradas no matagal, alegando que sequer sabia quais os tipos e quantidade que ali havia. Negou também que portava 14 porções de maconha, 4 pinos de cocaína e R\$ 48,00, consignando que o bolso da sua bermuda era pequeno e que nele não cabia tantas coisas.

Interrogado em juízo (gravação), o réu novamente negou o tráfico e, em linhas gerais, manteve a versão anterior, alterando-a, entretanto, em alguns pontos, quais sejam: disse que, por ocasião da abordagem, além da maconha e seda, portava R\$ 30,00, troco do barbeiro; negou ter autorizado os policiais a ingressarem em sua casa, alegando que eles perguntaram o que tinha lá e foram entrando. Acrescentou que conhece Álvaro desde criança, mas depois que ele mudou de escola e passou a vender drogas, parou de "andar" com ele. Os policiais lhe disseram no dia da ocorrência que Álvaro o havia delatado como traficante. Aduziu que, depois desse dia, os policiais estiveram mais umas três vezes na casa de Álvaro e ingressaram lá. Declarou que trabalha em empregos lícitos há muitos anos; que não conhecia os policiais anteriormente; que não tinha desavenças anteriores com eles; que eles entraram em contradição sobre o que disseram na delegacia a respeito das balanças; que na época dos fatos era usuário apenas maconha e não de cocaína.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Adalberto da Costa Filho declarou que, na data dos fatos, estava com seu colega em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o acusado parado no local dos fatos e viram que, ao notar a aproximação da viatura, ele externou nervosismo, fato que, aliado à circunstância de aquela rua ser conhecida como ponto de tráfico, ensejou sua abordagem para averiguação. Submetido à revista pessoal, encontraram em poder dele, no bolso de sua bermuda (fotografada às fls. 315), 14 porções de maconha, individualmente embaladas, bem como 4 pinos plásticos de cor amarela, contendo cocaína (fotografadas às fls. 20, no quarto

inferior), e R\$48,00 em dinheiro trocado. Indagado, o réu alegou que as drogas eram destinadas a seu consumo. Com a ajuda de cão farejador, fizeram varredura num terreno baldio com mata existente na frente ao local da abordagem e lá encontraram uma sacola plástica contendo mais 06 porções maconha, parte já fracionada e embalada, e outra parte em fração de maior dimensão, bem como outros 45 pinos amarelos, iguais aos que foram encontrados em poder do acusado, contendo cocaína, além de mais 94 pinos verdes com a mesma substância, além de duas balanças digitais. Indagado sobre tais substâncias e objetos, o réu disse desconhecer-las. Após, ele autorizou a entrada em sua residência para averiguação, a qual situava-se no mesmo local da abordagem. Localizaram no quarto do acusado outras duas balanças de precisão (as duas maiores que aparecem do lado esquerdo da fotografia de fls. 19) e uma importância em dinheiro, em notas diversas. Entretanto, ali não havia drogas. O réu alegou que o dinheiro era do auxílio que recebia e, quando foi informado que havia quantia maior, disse que parte seria do pai. Esclareceu que, no momento da abordagem, só havia o réu na rua e ele não estava preparando um cigarro de maconha para usar. Admitiu que perguntaram ao réu a respeito de uma pessoa de nome Álvaro, sobre o qual pesavam denúncias de tráfico, pois quando abordavam usuários na rua, eles diziam que haviam comprado entorpecente desse rapaz. Esclareceu que, sobre o réu, não pesavam denúncias de tráfico e não o conhecia anteriormente. Disse que, geralmente, um traficante de drogas não fica na posse de toda droga que vai vender, sendo muito comum o modus operandi de esconder parte dos entorpecentes nas redondezas. Por fim, afirmou que algumas equipes de polícia já fizeram prisões por tráfico no local.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Michel Dias Penachioni na fase informativa (fls. 04) e em juízo (gravação), o qual não confirmou apenas uma informação trazida por seu colega, qual seja, a respeito do suposto traficante de nome Álvaro, dizendo que ele próprio não perguntou ao réu sobre tal pessoa.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos

agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos policiais militares não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

As testemunhas arroladas pela defesa e ouvidas em juízo (gravação) não presenciaram a abordagem, revista do réu e encontro das drogas com ele e no terreno. Apenas fizeram declarações favoráveis sobre sua pessoa e esclareceram fatos circunstanciais.

Com efeito, Pedro Rubens Olivier (gravação) declarou que o réu trabalhou de 2015 a 2020, como atendente de mesa, em seu restaurante. Ele pediu demissão porque tinha conseguido um emprego no qual iria ganhar mais do que ganhava ali. Nunca soube de nenhum fato que o desabonasse. Desconhece seu envolvimento com tráfico de drogas.

Suzimari Santos da Silva (gravação) afirmou que conhece o réu desde pequeno, pois foi criado com seu filho. Há mais de 20 anos mora a um quarteirão de distância da casa dele. Sabe que ele é bom menino. Nunca o viu vendendo drogas no local dos fatos. Na esquina da rua casa dele há um ponto de tráfico de drogas, onde mora um rapaz de nome Álvaro. Os pais dele tinham uma empresa de venda de rações.

A irmã do réu, Lais Milena Bertolino (gravação) afirmou que estava trabalhando quando a mãe ligou desesperada avisando sobre a prisão dele. Saiu e viu as viaturas passando com o réu e foi atrás deles na delegacia. Disse que o irmão costumava ficar na frente de sua casa. Nunca o viu usando maconha. Foram encontradas em sua casa duas balanças, uma grade e uma pequena, as quais foram adquiridas por seu pai no Mercado Livre. Ele iria usá-las no negócio de venda de ração que realizava na época da aquisição. Ele também as usava no trabalho de padeiro. A quantia em dinheiro que foi apreendida era do seguro-desemprego do réu, em torno de R\$ 1.500,00 a R\$ 1.600,00. O dinheiro estava na carteira de sua mãe, que costumava ficar no quarto ou na sala. O réu sempre trabalhou, desde novo. Depois que obteve a liberdade, ele voltou ao emprego anterior numa usina. Conhece a pessoa de nome Álvaro, o qual mora duas casas de distância da sua. Explicou que há apenas 3 casas ali e a rua é pequena, sem saída. Sua casa é a última da rua e a de Álvaro é a primeira, de portão verde. Ele é o traficante que vende drogas na rua da sua casa e que guarda os entorpecentes no terreno existente na frente da sua casa. Já o presenciou entrando e saindo dali para pegar drogas. Depois da prisão do réu, viu pessoas comprando drogas de Álvaro na casa dele e o viu acessando esse terreno onde seus entorpecentes ficavam guardados e tentou filmar, mas não conseguiu. Por fim, afirmou que o réu dorme sozinho num quarto da casa.

O pai do réu, Agnaldo Misael Bertolino (gravação), declarou que também não viu a abordagem, pois estava saindo para pegar a esposa no trabalho. Afirmou que, na época dos fatos, seu filho fumava maconha, mas, depois da ocorrência, parou. Não permitia que ele usasse drogas dentro de sua casa, motivo pelo qual ele usava na rua. A balança maior e uma das menores fotografadas às fls. 19 foram encontradas em sua casa. Comprou-as pelo Mercado Livre pagando com seu cartão. Iria utilizar a grande para pesar ração, negócio que estava iniciando, e a pequena para pesar ingredientes de pão e receitas. A quantia em dinheiro encontrada em sua residência era composta de notas maiores, era do seguro desemprego do réu e era guardada na carteira de sua esposa, que ficava numa estante da sala. Seu vizinho Álvaro realiza tráfico de drogas na rua de sua casa, fazendo a distribuição dos entorpecentes para outros rapazes. Ele guardava as drogas no terreno situado na frente de sua residência. Após os fatos, policiais civis e militares estiveram lá à procura de Álvaro. O réu trabalha desde os 16 anos. Ele estava trabalhando na Usina Costa Pinto e foi dispensado por causa da pandemia, mas agora foi chamado de volta ao trabalho.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que, na data e local dos fatos, o réu trazia consigo as 14 porções de maconha e as 4 de cocaína descritas na denúncia.

Também restou demonstrado que tais substâncias eram destinadas ao tráfico.

De fato, a negativa do réu quanto à posse dessas drogas foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais, os quais restaram incólumes e comprovaram que o réu foi surpreendido parado no local dos fatos e que ele agiu de forma suspeita ao notar a aproximação da viatura, demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem e o encontro em seu poder de tais substâncias.

Essa prova afasta completamente a versão do acusado de que possuía apenas uma porção de maconha para seu uso, a qual não encontra ressonância em nenhuma outra prova do processo e, portanto, não pode ser acolhida.

A prova analisada também demonstrou que ele não possuía cigarro, seda ou nenhum

outro petrecho comumente utilizado para o consumo de maconha, afastando completamente sua versão neste sentido.

Contrariamente, comprovou que, além da diversidade de drogas, ele portava dinheiro, certamente obtido com as vendas realizadas naquele dia.

Acrescente-se a isso o fato de local onde o réu estava postado, não obstante ser na frente de sua residência, era uma rua já conhecida nos meios policiais como ponto de venda de drogas.

Nesta situação, e considerando a prova produzida pela própria defesa de que, na época dos fatos, o réu era usuário apenas de maconha e não de cocaína (ele próprio afirmou no interrogatório judicial que não usava o segundo tipo de droga), não há dúvidas de que o destino dos entorpecentes encontrados com ele era o comércio, pois se ele não usava cocaína, é evidente que portava, ao menos as porções desse tipo de entorpecente, para a venda.

A conclusão do destino mercantil também se deve à quantidade de entorpecentes que ele portava, incompatível com a situação de mero usuário, tanto que, para tentar se livrar da imputação mais grave, o réu alegou que tinha consigo apenas uma porção de maconha.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolvição – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal –

Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e periculosidade – Ré que ostenta processo por ato infracional – O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) – Regime fechado – Necessidade – Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Entretanto, quanto aos demais entorpecentes e balanças de precisão encontrados no terreno baldio situado na frente do ponto onde réu estava postado para exercer o tráfico, não obstante haja indícios de que poderiam também ser dele, notadamente porque parte das porções de cocaína estavam embaladas em pinos amarelos idênticos aos que ele portava, por outro lado, também não há como se afastar a hipótese de que poderiam pertencer ao rapaz de nome Álvaro, apontado pelo réu e pelas testemunhas de defesa como sendo o traficante que distribuía drogas ali e cujo nome foi mencionado pelo próprio policial que atuou na ocorrência, Adalberto Costa, o qual afirmou que tinham informação de que um rapaz de nome (Álvaro), citado por usuários, traficava no local e chegou a indagar o réu sobre ele.

Dessa forma, havendo suspeita de que ali também atuava outro traficante e considerando que o local dos fatos era uma rua pequena, sem saída, e, portanto, com pouca movimentação de pessoas, não há como entender que as drogas escondidas no terreno pertenciam ao réu e não ao outro suposto traficante que ali também estaria exercendo o nefasto comércio ilícito, o qual poderia tê-las guardado ali em momento pretérito.

Essa hipótese, porém, também não afasta a prova de que o réu portava as diversas porções de diferentes tipos de drogas apreendidas com ele (maconha e cocaína) e que estava traficando no local, devendo, assim, ser responsabilizado pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto ao dinheiro e as duas balanças de precisão encontradas em sua casa, em razão das provas trazidas pela defesa indicativas de que, respectivamente, seriam provenientes de seguro desemprego e relacionadas ao trabalho do pai do réu, também não há como se relacioná-las ao tráfico.

A perícia de fls. 340/343 não contribuiu para comprovação de que tais balanças eram usadas pelo réu para o tráfico, pois concluiu que, das quatro balanças apreendidas no dia dos fatos, duas tinham resquícios de substâncias entorpecentes. No entanto, não há como se saber se essas duas balanças eram as que estavam na casa do réu ou as que estavam no terreno baldio junto com as demais drogas.

No caso, restou comprovada apenas a origem ilícita do dinheiro apreendido em poder do réu no momento da abordagem policial (R\$ 48,00), o qual foi localizado junto com os entorpecentes destinados ao tráfico e em notas trocadas, em claro indicativo de que era proveniente das vendas ilícitas.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. fls. 38/41).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A existência de diversidade de drogas e a quantidade relacionadas ao réu não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistem atenuantes, agravantes ou causas de aumento das penas.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, até porque não foi tão expressiva a quantidade de drogas a ele relacionada, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de "envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a

denúncia e CONDENO o réu GUILHERME HENRIQUE BERTOLINO a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, conforme exposto acima, a quantia apreendida em poder do acusado (R\$ 48,00) é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA